

Roj: **STS 8534/2001 - ECLI:ES:TS:2001:8534**Id Cendoj: **28079110012001102515**Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**Sede: **Madrid**Sección: **1**Fecha: **02/11/2001**Nº de Recurso: **2121/1996**Nº de Resolución: **1001/2001**Procedimiento: **RECURSO DE CASACIÓN**Ponente: **FRANCISCO MARIN CASTAN**Tipo de Resolución: **Sentencia**

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dos de Noviembre de dos mil uno.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados indicados al margen, ha visto el presente recurso de casación interpuesto por el Procurador D. Luis Pastor Ferrer, en nombre y representación de D. Gabriel y D^a Elisa, contra la sentencia dictada con fecha 3 de junio de 1996 por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Zaragoza en el recurso de apelación nº 138/96 dimanante de los autos de juicio declarativo de menor cuantía nº 350/95 del Juzgado de Primera Instancia nº 13 de Zaragoza, sobre reclamación de cantidad por contrato de crédito. Ha sido parte recurrida la entidad Banco Español de Crédito S.A., representada por el Procurador D. Carlos Ibáñez de la Cadiniere.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 28 de abril de 1995 se presentó demanda interpuesta por la entidad Banco Español de Crédito S.A. contra D^a Elisa y D. Gabriel solicitando se dictara sentencia por la que se condenase a los demandados "a pagar solidariamente al actor la cantidad que le adeudan de 6.294.249,- Pts,- (SEIS MILLONES DOSCIENTAS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y NUEVE PESETAS), con sus intereses legales de demora al tipo pactado del 22% anual desde la última liquidación de la cuenta de la Póliza cuyo importe se reclama al 14-3-95 hasta el completo abono, y las costas totales del procedimiento".

SEGUNDO.- Turnada la demanda al Juzgado de Primera Instancia nº 13 de Zaragoza, dando lugar a los autos nº 350/95 de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, y emplazados los demandados, éstos comparecieron bajo una misma representación y contestaron a la demanda planteando como cuestiones previas las excepciones de litispendencia y cuestión prejudicial penal y, además, oponiéndose en el fondo, todo ello para que se dictara sentencia "por la que se estimen algunas de las excepciones invocadas y para el caso de no estimar ninguna excepción se desestime la demanda, en cualquiera de los casos absolviendo a mis mandantes de dicha demanda e imponiendo las costas de este litigio a la parte actora".

TERCERO.- Recibido el pleito a prueba y seguido por sus trámites, el Ilmo. Sr. Magistrado- Juez del mencionado Juzgado dictó sentencia con fecha 1 de diciembre de 1995 cuyo Fallo es del siguiente tenor literal: "Que estimando íntegramente como estimo la demanda formulada por la representación procesal de "BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.", contra D^a Elisa y contra D. Gabriel, debo condenar y condeno a los demandados citados, a que abonen a la actora, la suma reclamada de 6.294.249,-ptas. (SEIS MILLONES DOSCIENTAS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y NUEVE PESETAS), más sus intereses legales desde la fecha de la interpelación judicial hasta su pago, con expresa condena en costas a los demandados citados", el cual fue aclarado por Auto del siguiente día 14 "en el sentido de que donde dice "... más sus intereses legales desde la fecha de la interpelación judicial..." se entenderá dice "... más el interés del 22% desde el día 14 de Marzo de 1995".

CUARTO.- Interpuesto por los demandados contra dicha sentencia recurso de apelación, que se tramitó con el nº 138/96 de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Zaragoza y admitida prueba documental

aportada por la parte apelante sin necesidad de acordar el recibimiento a prueba en segunda instancia, dicho Tribunal dictó sentencia en fecha 3 de julio de 1996 con el siguiente fallo: "Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por D^a Elisa y D. Gabriel contra la Sentencia de 1 de Diciembre de 1.995, dictada por el Juzgado de Primera Instancia Número Trece de Zaragoza, en autos de menor cuantía número 350 de 1.995, debemos revocar en parte dicha resolución condenando a los demandados a que abonen al Banco Español de Crédito la cantidad de 6.294.249, ptas. (SEIS MILLONES DOSCIENTAS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y NUEVE PESETAS) más los intereses pactados en la cláusula segunda de la póliza (7%) desde la interposición judicial. Todo ello sin hacer especial declaración sobre las costas de ambas instancias."

QUINTO.- Anunciado recurso de casación por los demandados-apelantes contra la sentencia de apelación, el Tribunal de instancia lo tuvo por preparado y dicha parte, representada por el Procurador D. Carlos Ibáñez de la Cadiniere, lo interpuso ante esta Sala articulándolo en seis motivos amparados en el ordinal 4º del art. 1692 LEC: el primero por infracción del art. 1265 en relación con los arts. 1269 y 1270, todos del CC, y de la jurisprudencia al respecto; el segundo, por infracción de los arts. 1275, 1305.2 y 1306 CC y de la jurisprudencia al respecto; el tercero por infracción de la D.Tª 3ª CC en relación con los arts. 74, 80, 79, 75.3 y 76.1 LSA y con la Circular del Banco de España 8/89; el cuarto por infracción del art. 6.3 CC en relación con los arts. 167 C.Com. y 10.4 II de la LGCU; el quinto por infracción de este último precepto; y el sexto por infracción de los arts. 1265 y 1266.1 CC y jurisprudencia al respecto.

SEXTO.- Personada la entidad actora Banco Español de Crédito S.A. como recurrida por medio del Procurador D. Carlos Ibáñez de la Cadiniere, evacuado por el Ministerio Fiscal el trámite del art. 1709 LEC con la fórmula de "visto" y admitido el recurso por Auto de 15 de enero de 1997, la mencionada parte recurrida presentó su escrito de impugnación, solicitando se declarase no haber lugar al recurso con imposición de costas a la parte recurrente.

SÉPTIMO.- Por Providencia de 4 de julio del corriente año se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver el recurso sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 16 de octubre siguiente, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. FRANCISCO MARÍN CASTÁN

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El presente recurso de casación dimana de un juicio de menor cuantía promovido por la entidad Banco Español de Crédito S.A. en reclamación de 6.294.249 ptas. como saldo final de una póliza de crédito por 5.000.000 de ptas. suscrita seis años y cuatro meses antes.

Los cónyuges demandados contestaron a la demanda proponiendo las excepciones de litispendencia y cuestión prejudicial penal y, además, oponiéndose en cuanto al fondo dadas las peculiaridades de la operación subyacente a la póliza de crédito, cuyo importe estaba en realidad destinado a adquirir acciones del propio Banco sin coste real alguno para aquéllos, ya que los intereses se irían atendiendo con los dividendos de las acciones y el principal se amortizaría con el producto de la venta de las propias acciones. A este respecto los demandados se decían engañados por el Banco, ya que no habían podido disponer del dinero más que para la compra de las acciones y desconocían qué había ocurrido con éstas; y si bien en los fundamentos de derecho aducían que con base en los arts. 1305 y 1306-2ª CC ellos podrían pedir la entrega de las acciones sin pagar nada a cambio, "lo que no hacemos, puesto que mis mandantes sólo pretenden la nulidad de todo lo sucedido y olvidarse de este asunto", lo cierto es que en los pedimentos de la contestación se limitaron a solicitar la estimación de las excepciones articuladas o, de entrarse a conocer del fondo, la desestimación de la demanda, sin formular por tanto petición alguna de nulidad de la compraventa de acciones.

La sentencia de primera instancia declaró probado que la entidad demandante había invertido efectivamente el dinero en adquirir acciones a nombre de los demandados; que las acciones así compradas habían producido dividendos pasivos y derechos en periodos sucesivos, los cuales eran ingresados en la cuenta de la parte demandada con aquiescencia de ésta; y en fin, que esta misma parte había llegado a adquirir nuevas acciones en la misma forma que las primeras, "esto es, instrumentando la obtención del líquido preciso para ello mediante previo concierto con la demandante". En virtud de tales hechos, y entendiéndolo que los demandados habían contratado libremente, sin vicio alguno en su voluntad, y se habían aprovechado de los efectos beneficiosos de la operación mientras la situación económica permitió que se produjeran, estimó íntegramente la demanda.

Interpuesto recurso de apelación por los cónyuges demandados el tribunal de segunda instancia lo desestimó en lo sustancial, confirmando el fallo apelado salvo en lo relativo al tipo de interés aplicable desde la

interposición de la demanda, porque los apelantes no habían denunciado vicio alguno del consentimiento hasta verse demandados y la sanción civil de nulidad no era procedente, pese a lo dispuesto en el art. 167. C.Com., porque a tenor de la D. Transitoria 3ª CC tenían que aplicarse los criterios más benignos que informaban los arts. 74, 80, 79, 75 y 76 de la LSA de 1989 y la Circular del Banco de España 8/89.

Contra esta última sentencia ha recurrido en casación la parte demandada-apelante mediante seis motivos formulados al amparo del ordinal 4º del art. 1692 LEC, ninguno de los cuales se funda en error de derecho en la apreciación de la prueba.

SEGUNDO.- De lo antedicho se desprende que el supuesto de hecho es prácticamente idéntico al del recurso de casación nº 556/96, resuelto por sentencia de esta Sala de 10 de mayo del corriente año, llegando la coincidencia hasta el punto de ser el mismo el tribunal de apelación que ha dictado la sentencia recurrida, si bien en aquel otro caso la parte demandada había formulado reconvención para que se declarase nula la compraventa de acciones y el crédito "condicionado" a la misma, mientras que en éste no ha mediado petición formal alguna de nulidad.

Se razonó entonces por esta Sala para desestimar el recurso de casación, igualmente interpuesto por los demandados- apelantes, que la causa y la efectividad de la operación se desprendían inequívocamente de los propios hechos de la reconvención formulada en su día por aquéllos, quienes habían firmado una póliza de crédito y una orden de compra de acciones del Banco con el fin último de conseguir un lucro legítimo al cabo del tiempo sin tener que hacer desembolso material alguno; el "que este fin no llegara a lograrse es algo que no puede teñir retroactivamente de ilicitud a la causa lucrativa de la operación ni hacerla desaparecer por frustración de la finalidad última perseguida, ya que no cabe confundir la causa del contrato como elemento esencial para su validez con el buen fin de la operación o consecución del lucro inicialmente proyectado, y menos todavía cuando éste dependía necesariamente de las fluctuaciones inherentes a los valores negociables en bolsa, siendo inimaginable que los hoy recurrentes hubieran solicitado la nulidad de los contratos de haber evolucionado favorablemente la cotización de las acciones compradas y haberse podido cancelar entonces el crédito en la forma inicialmente proyectada".

En cuanto a la presunta infracción del art. 6 CC en relación con los arts. 167 C.Com. y 47 de la LSA de 1951, esta Sala no la apreciaba por las siguientes razones: "Primera, porque las acciones fueron adquiridas por los recurrentes, no por el propio Banco o sociedad, de suerte que carece de base la cita del art. 47 de la LSA de 1951 como norma prohibitiva; segunda, porque el motivo prescinde casi por completo de los razonamientos de la sentencia recurrida acerca de la atenuación del rigor del art. 6.3 CC cuando, como en este caso, sobreviene una profunda modificación normativa que, al poco de celebrarse los contratos y durante la vida de éstos, deroga la norma prohibitiva; tercera, porque la flexibilidad y prudencia del tribunal de apelación frente a la petición de nulidad fundada en la prohibición del art. 167 C.Com., derogado meses después de firmarse la póliza de crédito y la orden de compra de las acciones, se encuentra ciertamente avalada por la jurisprudencia de esta Sala que aconseja "extrema prudencia y criterios flexibles" cuando se trata de declarar la nulidad plena (SSTS 17-10-87, 15-12-93 y 22-7-97); y cuarta, porque la carta dirigida en su momento por los recurrentes al Banco comprometiéndose a no vender las acciones hasta tres años y medio después y a venderlas luego sólo escalonadamente para atender la amortización del crédito con sus intereses, hasta la cancelación de éste, ofrecía más los rasgos de un compromiso personal que los elementos y caracteres propios de una verdadera garantía incardinable en la prohibición del derogado art. 167 C.Com., ya que ni al Banco se le daba un derecho a instar la enajenación de las acciones ni los recurrentes tenían impedimento legal para enajenarlas por propia iniciativa".

TERCERO.- Pues bien, aunque el número de motivos del presente recurso sea mayor, procede mantener idéntica respuesta desestimatoria por darse las mismas razones de fondo, a las que ahora se une además, en lo procesal, la de no haber mediado petición formal alguna de nulidad fundada en los vicios del consentimiento alegados por la parte hoy recurrente al contestar a la demanda, petición que según doctrina reiterada de esta Sala habría exigido formular reconvención (SSTS 25-5-87, 6-10-88, 22-12-92, 21-5-97, 11-5-98, 16-10-99 y 9-5-01 entre otras).

Así el motivo primero, fundado en infracción del art. 1265 en relación con los arts. 1269 y 1270 I, todos del CC, y con la jurisprudencia al respecto, insiste en la actitud dolosa del Banco demandante, cifrando el dolo en que dicho Banco habría ocultado cuál era el patrimonio real de la entidad y por tanto el valor real de sus acciones. Pero semejante planteamiento no puede ser acogido por las siguientes razones: primera, porque la apreciación de los presupuestos fácticos del dolo corresponde a los órganos de instancia, y en este caso ni aparecen constatados en la sentencia recurrida ni en el recurso se articula motivo alguno fundado en error de derecho en la apreciación de la prueba que permita incorporarlos a los hechos probados; segunda, porque la parte hoy recurrente, al contestar a la demanda, alegó ciertamente el dolo de la actora, pero sin acompañar tal alegación de petición formal alguna de anulabilidad por dicho vicio del consentimiento; y tercera, porque

aceptar el argumento de fondo de este motivo equivaldría considerar nula toda compraventa de acciones cuya cotización no se correspondiera en el momento de la operación con la verdadera situación patrimonial de la sociedad en ese mismo momento, algo que resulta incompatible con el funcionamiento del mercado de valores y que produciría situaciones caóticas en forma de sucesivas nulidades retroactivas de las operaciones bursátiles cada vez que una compañía entrara en crisis.

El motivo segundo, fundado en infracción de los arts. 1275, 1305.2 y 1306 CC y de la jurisprudencia de esta Sala, alega ilicitud de la causa de la operación crediticia insistiendo en la ocultación de la verdadera situación patrimonial del Banco. Pero descartada ya la relevancia de este argumento, debe recordarse también lo razonado por esta Sala en su citada sentencia de 10-5-01 sobre la existencia de causa, y añadir además que la causa de la operación crediticia era lícita, ya que ambas partes estaban de acuerdo en que el dinero se destinara a comprar acciones del Banco y así se hizo, por más que finalmente la parte hoy recurrente no lograra el resultado esperado en cuanto a la cotización de las acciones al vencimiento de la póliza de crédito, frustración que en verdad es un riesgo en sí mismo inherente a cualquier operación como la entonces libremente aceptada y querida por la parte hoy recurrente.

El motivo tercero, fundado en infracción de la Disposición Transitoria 3ª del CC en relación con la 13ª del mismo Cuerpo legal, con los arts. 74, 80 (apdos. 2 y 3), 79, 75.3 y 76.1 LSA y con la circular del Banco de España 8/89, combate los razonamientos de la sentencia recurrida acerca de la aplicabilidad de la norma más benigna y, por tanto, de los criterios menos estrictos del vigente Texto Refundido de la LSA. Pero ya se razonó por esta Sala en su citada sentencia de 10-5-01 cómo la flexibilidad y prudencia del tribunal de apelación se ajustaban a la jurisprudencia que aconsejaba extrema prudencia y criterios flexibles a la hora de declarar una nulidad plena fundada en el art. 167 C.Com. vigente al concertarse la operación, máxime cuando es indiscutible que, de haber resultado ésta finalmente ventajosa para la parte hoy recurrente, nunca habría pedido la nulidad. Además, en el proceso causante de este recurso de casación la parte demandada-recurrente nunca ha llegado a pedir formalmente la nulidad de la compraventa de acciones, por más que en los fundamentos de derecho de su contestación a la demanda manifestara pretender "la nulidad de todo lo sucedido y olvidarse de este asunto", defecto que, de aceptarse el planteamiento de este recurso de casación, conduciría al absurdo de desestimar la reclamación del dinero con que se compraron las acciones para los demandados-recurrentes y, en cambio, subsistir la titularidad de éstos sobre tales acciones.

El motivo cuarto, fundado en infracción del art. 6.3 CC en relación con el art. 167 C.Com. y con el art. 10.4 II de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, es una especie de complemento del anterior para cuya desestimación basta con remitirse a lo ya razonado en esta sentencia y en la de 10-5-01, debiendo no obstante destacarse que como la sentencia recurrida no declara probada garantía formal alguna a favor del Banco sobre las acciones que compraron los demandados-recurrentes, este motivo incurre en el vicio casacional de la petición de principio o hacer supuesto de la cuestión, pues en relación con el art. 167 C.Com. la sentencia impugnada apunta una mera hipótesis ("las infracciones que la entidad crediticia hubiera podido cometer").

El motivo quinto, fundado en infracción de art. 10.4 II de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en su redacción vigente al tiempo de suscribirse la póliza de crédito, hace una larga exposición sobre el espíritu, sentido y finalidad de dicha ley, pero a la hora de concretar su infracción por la sentencia recurrida acaba prescindiendo prácticamente por completo de las cláusulas de la póliza litigiosa para, de un modo general, pedir su nulidad por no ser justo ni equitativo que los demandados-recurrentes hayan de pagar ahora por una acciones que "no valen ni siquiera cinco veces menos de lo que se les dijo valían cuando las compraron", considerando a modo de conclusión que "lo justo y lo lógico es la nulidad, de tal forma que los recurrentes no tengan que pagar ningún dinero y el banco recupere sus acciones valgan lo que valgan". Bien claramente se advierte, pues, que además de encubrirse una petición de nulidad de la compraventa de acciones no debidamente formulada en su momento, el motivo plantea algo que poco o nada tiene que ver con la defensa de los consumidores y usuarios, ya que los recurrentes suscribieron la póliza de crédito para una operación de índole claramente especulativa cuya frustración final no puede trasladar retroactivamente la operación crediticia a ese ámbito normativo.

Y el motivo sexto y último, en fin, fundado en infracción de los arts. 1265 y 1266.1 CC y de la jurisprudencia al respecto, debido al error que habría viciado el consentimiento de los demandados-recurrentes por desconocer éstos la verdadera situación patrimonial del Banco cuyas acciones compraron, vuelve a olvidar tanto la índole especulativa de esta concreta operación cuanto el riesgo en sí mismo inherente a las operaciones bursátiles, así como a desconocer que en el escrito de contestación a la demanda la anulabilidad de la operación crediticia por vicio del consentimiento no se pidió en forma mediante la necesaria reconvención, la cual tendría que haberse extendido además a la operación añadida de compra de acciones, plenamente consentida por cierto



en su momento según los hechos probados que declaran la aquiescencia de los demandados-recurrentes a los ingresos originados por dichas acciones y la posterior adquisición por ellos de nuevas acciones.

CUARTO.- No estimándose procedente ninguno de los motivos del recurso, debe declararse no haber lugar al mismo, con imposición de las costas a la parte recurrente conforme dispone el art. 1715.3 de la LEC de 1881.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Procurador D. Luis Pastor Ferrer, en nombre y representación de D. Gabriel y D^a Elisa , contra la sentencia dictada con fecha 3 de junio de 1996 por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Zaragoza en el recurso de apelación nº 138/96, imponiendo a dicha parte las costas causadas por su recurso de casación.

Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de Sala.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-José Almagro Nosete.-Xavier O'Callaghan Muñoz.- Francisco Marín Castán.- Firmado y Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Francisco Marín Castán, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.